

0005306-48.2018.8.26.0024

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Denúncia caluniosa

Magistrado: Pedro Luiz Fernandes Nery Rafael

Comarca: Andradina

Foro: Foro de Andradina

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 09/09/2022

... a prisão do acusado por conta de tráfico de drogas. Ele foi abordado, ficando com o Tenente Douglas. Dada voz de prisão ao Hélio ele tentou se evadir. No momento, foi feito uso de força moderada e meios de contenção - ele foi algemado para não fugir. Encontraram com ele R\$ 10,00 e mais R\$ 157,00, mais 13 porções de maconha. A partir desse momento ele começou a falar para a equipe que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Andradina

Foro de Andradina

3ª Vara

Rua Paes Leme, 2052, Andradina-SP - cep 16901-110

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0005306-48.2018.8.26.0024 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0005306-48.2018.8.26.0024

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Denúncia caluniosa

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 96/2018 - 02º D.P. ANDRADINA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HELIO MACIEL DA SILVA

O Ministério Público ofereceu denúncia contra HELIO MACIEL DA SILVA imputando-lhe a prática do crime de calúnia contra servidor público (Art. 138 "caput" c/c Art. 141 "caput", II c/c Art. 69 "caput", (duas vezes) todos do CP).

Narra a denúncia que (i) no dia 03 de fevereiro de 2018, por volta das 12 horas, na Rua Paes Leme, nº 2.052, Stella Maris, no interior do Fórum local, bem como (ii) no dia 14 de junho de 2018, no interior da Delegacia Seccional de Andradina, situada na São Francisco, nº 871, Benfica, ambos nesta cidade e comarca de Andradina, o réu, qualificado às fls.08/09 e 96 dos presentes autos, caluniou os policiais militares Douglas Piauí da Silva e Willian Calister de Almeida, imputando-lhes a prática do crime de abuso de autoridade, de que os sabia inocente (fls.67/72).

A denúncia foi recebida em 22 de novembro de 2021 em decisão de fl.180. O réu foi citado e apresentou resposta à acusação de fl. 190.

Após regular instrução, o Ministério Público manifestou-se pela condenação, entendendo demonstradas a materialidade e autoria do delito imputado; a d. Defesa, por sua vez, requereu a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, consideração da retratação do acusado.

É o relato do necessário. Fundamento e DECIDO.

Inexistem nulidades ou irregularidades a serem sanadas. O feito tramitou regularmente. Não foram arguidas preliminares ou questões prejudiciais aptas a impedir o prosseguimento da marcha processual, razão pela qual passo à análise do

mérito da lide.

Após detida análise das provas produzidas e sopesadas as alegações das partes, conclui-se pela procedência da acusação.

Com efeito, a ocorrência do delito foi demonstrada pelos elementos da investigação (inquérito policial de fl.01, termo de interrogatório de fl. 07, termo de depoimento de fls. 92 e 113, retratação de fls. 78/83, termo de declarações de fls. 95 e 105, laudos periciais de fls. 96/97), bem como pelo resultado da instrução em juízo.

A autoria também foi comprovada pelos elementos indicados, assim como pela prisão em flagrante e consistentes relatos das testemunhas.

A prova oral, produzida sob o crivo do contraditório, foi no seguinte sentido:

A vítima Willian Calister de Almeida, policial militar, narrou que realizaram a prisão do acusado por conta de tráfico de drogas. Ele foi abordado, ficando com o Tenente Douglas. Dada voz de prisão ao Hélio ele tentou se evadir. No momento, foi feito uso de força moderada e meios de contenção – ele foi algemado para não fugir. Encontraram com ele R\$ 10,00 e mais R\$ 157,00, mais 13 porções de maconha. A partir desse momento ele começou a falar para a equipe que os policiais estavam o prejudicando e que por esse motivo ele prejudicaria os policiais também, relatando que teria sido agredido. Na delegacia, no dia da elaboração do flagrante, em alto e bom som, ele continuava falando que prejudicaria os policiais. Desse modo, foi registrado junto com o flagrante, a inserção da situação da calúnia. O delegado chamou médico legista e não foi constatada qualquer lesão.

A testemunha e delegado de polícia, Thiago Rodrigues Barroca relatou que na data dos fatos o réu foi apresentado pelos policiais em razão de possível prática de tráfico de drogas, alegando que havia sido agredido pelos policiais. Foi realizado exame de corpo de delito, como de praxe, até porque sem tal providência o preso não seria recebido na Cadeia Pública. Salvo engano, não foi constatada nenhuma lesão. Deliberou por ratificar a voz de prisão em flagrante, ainda que o preso tenha relatado um prazo dilatado entre a ocorrência e a apresentação, inclusive pelo fato de que, em sua convicção, se os policiais tivessem decidido forjar qualquer situação o fariam rapidamente.

A testemunha e delegado de polícia, Marcelo da Silva Zompero afirmou que não presidiu o inquérito. À época respondia por diversas delegacias e por tal razão deve ter assinado o documento de fl. 95. Conversou com a escrivão ad hoc sobre os fatos, a qual confirmou o teor das declarações do acusado Hélio.

Douglas Piauí, também vítima, confirmou a versão de seu colega de profissão, sem divergências ou acréscimos dignos de nota.

Interrogado, o réu confirmou que foi abordado pelos policiais e que eles lhe aplicaram um mata-leão que o desmaiou. Em seguida, acordou recebendo chutes. Ficou com marcas vermelhas pelo corpo, mas o perito disse este tipo de marca não caberia apontar no laudo.

Diante desse contexto probatório, não há dúvidas de que a imputação do delito de calúnia contra policiais militares é procedente.

Veja-se que o acusado manifestou em audiência de custódia que teria sofrido agressões dos policiais, o que não foi atestado no laudo pericial de fl. 96/67. Em seguida, dias após, retratou-se, por meio dos advogados que o representaram inclusive quando da lavratura do flagrante (fls. 77/83). Não obstante, quando ouvido novamente na delegacia seccional de Andradina, retratou-se da retratação, por assim dizer, e reiterou a narrativa de que sofrera agressões (fl. 95). Em juízo, novamente trouxe tal alegação.

Em que pese a insistência do acusado, que inclusive em audiência realizada perante este juízo reiterou ter sido agredido, o quadro de provas indica de forma objetiva que a versão é falsa.

Veja-se que os policiais militares narraram que desde quando abordado, o acusado ofertou resistência ao ato e passou a dizer que os "prejudicaria".

O laudo pericial realizado logo após os fatos não atestou nenhuma lesão sofrida pelo réu, nem sequer escoriações, equimoses ou vermelhidão em sua pele.

Neste ponto, as justificativas do réu de que o perito teria constatado as marcas, mas teria deixado de as relatar no laudo, não são dignas de crédito, já que o

médico que faz o exame é sujeito absolutamente imparcial e alheio às eventuais e naturais rusgas e desentendimentos ocorridos entre policiais e criminosos. Ressalte-se que quando ouvido no flagrante, o réu trouxe uma versão detalhada de como os policiais teriam ficado por algumas horas procurando drogas para incriminá-lo, sem apontar em nenhum momento ter sofrido as agressões relatadas posteriormente. Anoto, mais uma vez, que estava representado por advogados quando de seu interrogatório extrajudicial.

E, quando ouvido à fl. 95, o réu relatou agressões de forma distinta do quanto dito em audiência de instrução, sendo então três versões distintas prestadas pelo réu sobre como os fatos teriam se desenrolado, além da retratação sobre a alegação de agressão.

Em suma, temos nos autos i) a confirmação dos policiais de que o réu indicou previamente, por assim dizer, que poderia fazer falsa acusação, ii) laudo pericial realizado por médico de forma imparcial atestando inexistência de qualquer marca de lesão (sendo que um estrangulamento até o desmaio, seguido de chutes desferidos por policiais calçando botas certamente teriam gerado lesões aparentes, e iii) uma sequência de versões contraditórias prestadas pelo réu, chegando inclusive a negar as agressões em petição ofertada pelos advogados que o representavam.

E o testemunho dos policiais não deve ser desacreditado apenas pela sua condição funcional. Não demonstraram ser tendenciosos ou qualquer especial disposição para prejudicar o réu, devendo o seu testemunho ser valorado como qualquer outro. Esta é a jurisprudência já pacífica sobre a condição de testemunha dos policiais militares e outros agentes de segurança.

Anoto que a retratação do acusado não pode servir para afastar a imputação, e, sim, para que o aumento na primeira fase restrinja-se aos antecedentes do acusado.

Assim, inexiste dúvida de que o réu imputou falsamente aos policiais fato criminoso, incorrendo então no art. 138, cumulado com o art. 141, II, ambos do CP. Impondo-se a condenação, resta a fixação da sanção correspondente.

Crítérios para fixação da pena:

Antes de iniciar a fixação da pena propriamente dita, cabem alguns esclarecimentos sobre os critérios gerais a serem utilizados para a dosimetria, especialmente sobre a forma de cálculo das frações de aumento e diminuição. A base de cálculo será o intervalo entre a pena mínima e máxima do delito, e não a pena mínima.

Na primeira fase, na qual fixa-se a pena-base, existem oito circunstâncias judiciais passíveis de valoração. A pena sempre partirá do mínimo previsto e, a cada circunstância judicial desfavorável ao acusado, somar-se-á à reprimenda mínima cominada a fração de um oitavo (pois são oito circunstâncias), calculada pelo intervalo entre o máximo e o mínimo de pena previstos em lei para o crime em questão. A partir deste intervalo entre a pena máxima e a mínima encontra-se a fração respectiva de um oitavo para cada circunstância desfavorável.

Exemplificando-se, para melhor compreensão: se um crime tem pena mínima de 12 anos e máxima de 20 (como ocorre com o tipo previsto no art. 159, § 1º do Código Penal), o cálculo das frações é feito sobre o intervalo de 8 anos entre a pena mínima e máxima, e não sobre os 12 anos da pena mínima. A cada circunstância negativa considerada somar-se-á à pena mínima 1/8 sobre oito anos, o que representa um ano.

Se não houver circunstância negativa, a pena-base será a mínima, de 12 anos; ao contrário, se todas forem desfavoráveis, a pena parte do máximo legal, 20 anos.

Tal forma possibilita ao mesmo tempo: i) controle sobre os patamares utilizados pelo julgador, que se move em espaço conferido pelo legislador por meio de critério racional; ii) proporcionalidade, pois cada circunstância terá, em regra, peso semelhante e será calculada de acordo com os patamares mínimo e máximo da pena, abarcando de forma global a gravidade do crime; iii) fixação da pena partindo sempre do mínimo legal, com a possibilidade de se chegar ao máximo previsto, caso as oito circunstâncias judiciais sejam desfavoráveis.

O critério também evita indesejáveis discrepâncias, como nos casos de crimes com pena mínima muito elevada ou diminuída. Se o cálculo partir da pena mínima, pode-se chegar a exasperações exageradas (como no caso da extorsão mediante sequestro seguida de morte, cuja pena mínima é de 24 anos) ou ínfimas (neste caso nunca se chegando perto da pena máxima cominada para o delito, como no crime de ameaça).

Ademais, permite que crimes que possuem a mesma pena mínima, mas diferentes penas máximas, justamente por serem de gravidade distinta (como a lesão corporal do caput e a figura do § 9º), sejam apenados adequadamente, cada um com sua gravidade e grau de censura já estipulados em lei. Seria injusto que para crimes de diferente gravidade a exasperação da pena-base partisse do mesmo patamar.

Via de regra, este será o critério utilizado na primeira fase. Diante da peculiaridade de cada caso as frações de cálculo poderão ser diminuídas ou aumentadas, para que se possa individualizar adequadamente a pena, de forma fundamentada (como por exemplo, nos casos de várias condenações criminais ou reincidência específica). O critério explicitado servirá sempre de parâmetro, porém não impedirá seja a pena-base fixada de modo diverso (para mais ou menos) se o caso assim recomendar (valendo isto também para a segunda fase).

Na segunda fase, na qual incidem agravantes e atenuantes, a fração usada para valoração será, no mais das vezes, de um sexto (1/6), calculado ou sobre o intervalo entre pena mínima e máxima, como acima, ou sobre a pena-base já fixada - o que for maior.

E utilizar-se-á o maior valor por uma razão simples: há uma hierarquia no sistema trifásico que deve ser respeitada. O sistema trifásico é escalonado, tendo cada fase maior relevância sobre a precedente. As circunstâncias do art. 59, valoradas pelo julgador, jamais podem preponderar sobre agravantes ou atenuantes, elevando a pena em patamar acima destas, que já foram estipuladas como mais graves de antemão pelo próprio legislador. A fração de 1/6 será utilizada pois é a menor prevista para as causas de diminuição e de aumento de pena e, com isso, respeita-se novamente a hierarquia do sistema trifásico.

Por fim, como não poderia deixar de ser, as causas de aumento ou de diminuição de pena incidirão sobre a reprimenda fixada provisoriamente na primeira e segunda fases, de forma sucessiva (incidindo umas sobre as outras, em cascata), segundo entendimento preponderante nos tribunais. Do contrário poderia se chegar ou a penas negativas, no caso de diversas causas de diminuição, ou na utilização de critérios distintos para causas de aumento e de diminuição, o que não é isonômico.

Friso que o critério ora explicitado vem sendo consagrado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (HC 498586 / SP - 5ª Turma - julgado em 11/02/2020), verbis:

"2. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo permitido ao julgador, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.

3. As agravantes não necessariamente incidem sobre o resultado da pena-base, cujo acréscimo de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância negativa multiplica o intervalo de pena decorrente da diferença entre a pena mínima e máxima cominadas ao tipo, para então somar à pena mínima. Portanto, as agravantes incidirão sobre a pena-base se for maior ou igual ao intervalo de pena em abstrato do preceito secundário, caso contrário, malgrado haver pena concreta dosada, as agravantes serão fixadas com parâmetro na base de cálculo das circunstâncias judiciais, sob pena de as agravantes serem menos gravosas do que meras circunstâncias judiciais".

E ainda (AgRg no REsp 1704633 / TO - 6ª Turma - julgado em 24/09/2019): "A divisão do intervalo entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato pelas oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP é um, entre outros, dos critérios que podem ser utilizados na fixação da pena-base".

Dito isso, passo efetivamente a fixar a pena.

Na primeira fase, observo que o acusado ostenta antecedente criminal, já que cometeu crime anterior ao fato deste processo (justamente o crime de tráfico que deu ensejo ao presente processo, cometido em 02/02/2018 - fl. 206), cujo trânsito se deu durante o trâmite deste feito. Veja-se, o entendimento do STJ sobre a matéria (HC 171212 / DF - 6ª Turma - DJe 20/08/2015): "O conceito de Maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação

penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes."

Cabe assim, exasperar sua pena-base em 1/8.

Ressalto que a pena parte do mínimo legal (6 meses) e a este patamar serão somados os montantes das frações encontradas a partir do intervalo entre a pena mínima e máxima, e não a partir da pena mínima.

NÃO SE TRATA DE UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO DO TERMO MÉDIO (O QUAL FARIA A PENA-BASE PARTIR DE 1 ANO E 3 MESES E NÃO DO MÍNIMO), TAMPOUCO DE ERRO ARITMÉTICO.

Trata-se de utilização de distinta base de cálculo para encontro das frações de mudança da pena, utilizando-se o resultado do intervalo entre a pena mínima e máxima, e não a pena mínima, critério este que considera a gravidade do crime de forma global conforme estipulada pelo legislador e mostra-se mais proporcional ao juízo prévio feito pelo parlamento sobre a natureza do crime (caso contrário, crimes com pena mínima igual e pena máxima diversas, como o estupro e o homicídio, o furto qualificado e a corrupção passiva, etc, teriam idêntico apenamento, o que não se mostra de fato adequado, pois o legislador já estabeleceu distinção prévia de gravidade, a ser observada pelo julgador; já crimes com penas mínimas muito elevadas, teriam exasperações exageradas, como a extorsão mediante sequestro com resultado morte, com pena mínima de 24 anos).

De toda forma, destaco novamente que o tópico acima ("critérios para fixação da pena") estabelece as justificativas pelas quais a individualização da pena resta melhor assegurada por esta forma de cálculo, que é diferente do padrão normalmente adotado (mais cômodo para cálculos, mas que desconsidera inúmeros fatores de proporção e postulados a respeito da prevalência dos critérios de lei sobre critérios subjetivos), mas que é referendado por argumentos racionais e também pela jurisprudência do STJ (HC 498586/SP - 5ª Turma - julgado em 11/02/2020 e AgRg no REsp 1704633/TO - 6ª Turma - julgado em 24/09/2019).

Feito novamente tal esclarecimento, adiciono à pena mínima (6 meses) o montante de 2 meses e 7 dias de detenção, montante equivalente a 1/8 de 18 meses (intervalo de pena previamente estipulado pelo legislador ao considerar globalmente a gravidade do crime, que tem pena de 6 meses a 2 anos) e estabeleço a pena-base em 8 meses e 7 dias e 53 dias-multa.

Na segunda fase, observo que o acusado é reincidente (fls. 206/207 e 228), pois teve pena privativa de liberdade extinta em 2015 e de multa em 2016.

Cabe então agravamento em 1/6, equivalente, pelo critério de cálculo acima explicitado (encontro da fração a partir do intervalo entre a pena mínima e máxima do delito), a 3 meses de reclusão e 58 dias-multa.

A pena chega então a 11 meses e 7 dias de detenção e 111 dias-multa.

Na terceira fase, incide a causa de aumento do art. 141, II, com elevação em 1/3. A pena intermediária então vai a 1 ano, 2 meses e 29 dias, e pagamento de 148 dias-multa.

Sendo assim, a pena fica em 1 ano, 2 meses e 29 dias, e pagamento de 148 dias-multa.

Entendo que a sequência de afirmações não pode ser considerada como novo fato criminoso, e sim espécie de continuidade ou desdobramento da primeira afirmação falsa. Os efeitos ao bem jurídico são os mesmos, não importando a quantidade de vezes em que a pessoa declara a acusação falsa.

Entretanto, sendo dois policiais como vítimas, cabe aumento da pena em razão do concurso formal, já que com apenas uma ação, o réu praticou calúnia contra duas pessoas distintas. Assim, com o aumento indicado, a pena vai a 1 ano, 5 meses e 13 dias de detenção e 129 dias-multa.

O regime inicial, tendo em vista a quantidade de pena, antecedentes e reincidência deve ser o semiaberto.

Inviável a substituição da pena, a se considerar as circunstâncias do crime, envolvendo calúnia contra policiais, revestida de gravidade portanto, além do réu ser reincidente e possuir antecedentes.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação e CONDENO HELIO MACIEL DA SILVA, pela prática do crime calúnia, previsto no art. Art. 138 "caput" c/c Art. 141 "caput", II c/c Art. 70, (duas vezes) todos do Código Penal, à pena de 1 ano, 5 meses e 13

dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 129 dias-multa, calculados em seu mínimo legal.

O réu poderá recorrer em liberdade.

Condene o réu ao pagamento das custas do processo em 100 UFESPs, com as ressalvas da gratuidade.

Com o trânsito, i) comunique-se ao IIRGD e ii) Justiça Eleitoral, ii) anote-se a condenação (art. 372 das NSCGJ) e iv) expeça-se guia de recolhimento.

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários ao advogado que atuou pelo convênio.

Publique-se. Intime-se na forma legal.

Andradina, 09 de setembro de 2022.

Pedro Luiz Fernandes Nery Rafael

Juiz de Direito

(assinatura eletrônica)